

1500072-83.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500072-83.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-83.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAIN MORENO AGUILAR e outro

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de SAIN MORENO AGUILAR e JORGE PATRÍCIO RODOUREIRA HIDALGO, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, art. 311 e art. 339, caput, todos do Código Penal, em concurso material de infrações, afirmando que em 02 de fevereiro de 2022, por volta de 11h45min, na rua Professor Emerson Aparecido Carandina, nº 385, bairro José Gomes, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, subtraíram dois televisores da marca LG de 50 e 42 polegadas, um notebook da marca Acer, um forno micro-ondas de inox da marca Brastemp, dois smartphones da marca Motorola e dois controles de videogame Xbox, bens pertencentes a Laura Helena Calbaiser da Silva; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, adulteraram a numeração da placa do veículo Citroen/C4 de EPO-6032 para EPO-8082 e, por fim, no dia 03 de fevereiro de 2022, Sain e Jorge deram causa à instauração de inquérito policial contra Diego Lima Pontes de Araújo e Diego Prinholato, imputando-lhes a prática de crimes de que sabiam serem inocentes.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "os denunciados, estrangeiros residentes na cidade de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios delituosos entre si, deslocaram-se no dia dos fatos até esta cidade de Porto Ferreira com o veículo Citroen/C4 a fim de praticarem o crime de furto, sendo este o meio de vida deles conforme se depreende da vasta folha de antecedentes que

possuem, notadamente por crimes patrimoniais e apreensão de petrechos destinados a tal prática ilícita (cf. F.A. e certidões às fls. 80/108 e 109/121 e auto de exibição de fls. 45/46). Ato contínuo, rumaram para a residência da vítima Laura e, após arrombarem os cadeados e fechaduras do portão e da porta, ingressaram no imóvel e subtraíram os objetos acima descritos, empreendendo fuga no veículo Citroen/C4. Contudo, comunicados via rádio do furto em andamento, policiais militares rapidamente se deslocaram ao endereço apontado e, nas proximidades do imóvel, cruzaram com o veículo Citroen/C4 reportado na informação, no que o condutor, ao notar a aproximação das viaturas das duas rodas, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo iniciada a perseguição, até que o automóvel se chocou contra o canteiro central, danificando o motor e estourando dois pneus. Os denunciados então abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé. O increpado SAIN MORENO foi alcançado ainda próximo do local do acidente, tendo oferecido resistência e legitimando o uso de força moderada para sua prisão e algemamento. Já JORGE PATRICIO somente foi alcançado e capturado a cerca de 300 metros do local do acidente, numa região de mata, com a ajuda de outros policiais. Na sequência os policiais arrecadaram os objetos furtados que estavam no interior do veículo dos denunciados (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 47/48), bem como ferramentas destinadas à subtração (cf. auto de exibição de fls. 45/46), tendo sido constatado, ainda, que a placa traseira do automóvel Citroen/C4 estava adulterada para dificultar a identificação, tendo sido aposta fita isolante sobre parte do numeral, passando, assim, da numeração EPO-6032 (original) para a EPO-8082 (adulterada), conforme documento e fotografia às fls. 60 e 61 e laudo pericial a ser oportunamente juntado. Por fim, quando ouvidos em audiência de custódia no dia 03 de fevereiro de 2022, ambos os denunciados afirmaram que os policiais militares Diego Lima Pontes de Araújo e Diego Prinholato, responsáveis pela prisão, praticaram os delitos de abuso de autoridade e lesão corporal, alegando JORGE PATRICIO ter sido agredido com tapas no rosto no momento da captura e SAIN MORENO com tapas, chute e soco na cabeça quando alcançado e capturado, dando causa, assim, à instauração de inquérito policial contra os agentes públicos (cf. despacho judicial e informação da Delegacia de Polícia às fls. 181/182). Contudo, é certo que os denunciados sabiam que os policiais militares eram inocentes quando fizeram a falsa acusação de agressão, pois além de ambos terem afirmado quando ouvidos pelo Delegado de Polícia que “não sofreram agressão por parte dos policiais que os prenderam” (fls. 07 e 30), também restou devidamente demonstrado nos autos que se envolveram em acidente automobilístico de considerável monta quando da fuga dado o estado que ficou o carro (fl. 59), sofrendo ferimentos deste evento e, para JORGE PATRICIO, quando fugiu à pé e caiu, bem como que SAIN MORENO ofertou resistência no momento da captura, sendo necessário o uso de força moderada para sua prisão e algemamento (fls. 02 e 04). Aliás, foi o que disse SAIN MORENO quando da anamnese no momento do atendimento médico, tendo sido consignado no documento que “Refere ter batido carro na fuga, onde se machucou (SIC)” (fl. 63), ao passo que JORGE PATRICIO consignou em sua anamnese que “Refere ter caído no chão ao tentar fugir” (fls. 69/70). Por fim, SAIN MORENO, em contradição com a dinâmica dos fatos, disse que teria visto JORGE PATRICIO sendo agredido no momento da captura, porém, após a colisão do veículo, aquele foi preso próximo ao local, enquanto este empreendeu fuga, sendo alcançado somente a cerca de 300 metros dali, em uma mata, de forma que o primeiro não poderia ter presenciado a captura do comparsa e as alegadas agressões. Assim, é certo que os denunciados deram causa à instauração de inquérito policial contra os policiais militares imputando-lhes crimes de que sabiam serem inocentes.”

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do STF. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse". Nesse sentido é válida a lição do Desembargador Francisco Loureiro sobre a cessação da clandestinidade:

A posse é clandestina (clam) quando se adquire via processo de ocultamento em relação àquele contra quem é praticado o apossamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit., p. 23). É um defeito relativo: oculta-se da pessoa que tem interesse em retomar a posse, embora possa ser ela pública para os demais. Na violência, retira-se o poder de reação do possuidor, que conhece a agressão à sua posse. Na clandestinidade, o possuidor não percebe a violação de seu direito, e por isso não pode reagir. Questão relevante é saber se para cessar a clandestinidade deve o esbulhado ter ciência inequívoca de que a coisa acha-se nas mãos do possuidor injusto ou, em vez disso, basta que o novo possuidor não mais oculte sua conduta. O melhor entendimento é que não há necessidade de que a vítima tenha efetivo conhecimento do esbulho, mas que o esbulhador torne possível à vítima conhecê-lo (Pinto, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo, RT, 1987, p. 107-8). Torna-se pública a posse quando nasce para a vítima a possibilidade de conhecer o esbulho. Loureiro, Francisco Eduardo. Código civil comentado. 8ª ed., Barueri, Manole, 2014, p. 1070.

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 37/40, pelo auto de avaliação de fls. 175/176 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O topo do artigo 311 do Código Penal assim prescreve:

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento

A identificação de veículos automotores está disciplinada pelos artigos 114 a 117 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.605/97) - CTB; com regulamentos

infralegais, notadamente a Resolução CONTRAN 24/98 e a ABNT NBR 3 n.º 6066. De modo resumido, o veículo possui uma identificação externa pelo número das placas (art. 115 do CTB) e uma identificação interna pela numeração do chassi ou monobloco (art. 114 do CTB), com reprodução em outras partes do veículo.

O tipo objetivo, assim, consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer outro sinal identificador. Fala-se em remarcação quando se apaga a numeração originária (ainda que parcialmente) e se substitui por outra. A adulteração pode se dar com qualquer espécie de montagem do chassi de um veículo em outro.

O bem jurídico protegido, conforme o REsp 503.960/SP (rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 19/04/2010), é "a fé pública e, especialmente, a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóvel". O julgado está em consonância com a Mensagem 784-MJ da Presidência da República que expõe a preocupação com as somas milionárias envolvidas no furto, roubo e receptação de veículos e cargas.

Como explica Victor Rios Gonçalves, "o crime em estudo é autônomo em relação a eventual furto ou receptação do veículo automotor, bem como no que diz respeito à falsificação do documento". Aliás, como bem lembra o Desembargador Guilherme Nucci, quando o agente comete crime de trânsito na posse de veículo cuja placa ele alterou, não responderá pela agravante do inciso II do art. 298 do Código de Trânsito, mas sim pelo concurso material com o art. 311 do Código Penal.

A existência da adulteração da placa do veículo automotor (identificação externa) está comprovada pelas fotos de fls. 60/61, pelo laudo pericial (fls.285/289) e também pela prova oral.

A autoria é certa

O topo do artigo 339 do Código Penal assim prescreve:

Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

Trata-se de crime contra a administração da justiça. Enquanto na calúnia o dolo é de macular a honra da vítima, na denúncia caluniosa o dolo é de criar um procedimento (inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade) inútil e desnecessário imputando a autoria a alguém (sem esta imputação incidirá o tipo de comunicação falsa de crime ou contravenção) que também quer-se prejudicar, justamente por saber que ela é inocente do crime, infração ético disciplinar ou ato de improbidade.

A imputação deve ser falsa objetivamente (se a pessoa apontada praticou o fato não incide o tipo penal) e subjetivamente falsa (o agente deve saber que a pessoa apontada não praticou o fato).

O tipo incide quando o crime sequer existiu ou quando o crime existiu, mas apontou-se falsa autoria.

O agente pode dar causa de forma direta (sem intermediários, perante a autoridade responsável pelo procedimento) ou indireta (por meio de denúncia anônima ou terceiro de boa-fé).

De qualquer forma, este relato deve ser espontâneo e não provocado. Caso seja feito por uma testemunha, responderá por falso testemunho.

Prevalecem os entendimentos de que a imputação do fato seguida de uma excludente de ilicitude ou de afastamento da responsabilidade criminal não configuram o delito.

O dolo é necessariamente o direto, só incidindo quando o agente sabe da inocência da pessoa apontada. Se tem dúvidas e assume o risco (dolo eventual), não há o delito.

O ponto central, assim, é o conhecimento do agente. Se ele sabe da inocência de uma pessoa e diz que acha que ela praticou o fato incidirá no tipo. Mas, de outro lado, se tem reais dúvidas e aponta alguém como suspeito não comete o crime.

O crime se consuma quando o procedimento é iniciado. Não é necessário, em âmbito criminal, que o inquérito seja instaurado, bastando que qualquer diligência seja praticada.

Gritante é a fragilidade probatória relativa à denúncia caluniosa.

O tipo da denúncia caluniosa exige a instauração do procedimento para sua consumação. No caso, a denúncia somente apontou um e-mail da escrivã de polícia civil dizendo que houve a abertura de inquérito policial sem sequer citar o número do procedimento (ou diligência nele executada) para que houvesse um efetivo exercício do direito de defesa e dimensão da lesão ao bem jurídico. O que se juntou àquele momento não foi a prova da instauração, mas uma notícia dessa instauração. E é dever da acusação apontar, já na denúncia, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias (art. 41 do Código de Processo Penal).

Um aqodamento que já se notava na audiência de apresentação, quando, naquele momento, o representante do Ministério Público exibiu sua convicção acerca do tipo do art. 339, caso não comprovadas as acusações feitas pelas pessoas presas, quando, como se sabe, não basta a não comprovação da denúncia, mas também a ciência inequívoca de que fora feita sabendo-se da inocência do denunciado.

Até porque, levado a cabo a linha de raciocínio do Ministério Público, os representantes da instituição deveriam automaticamente responder pelo delito a cada absolvição em ação penal pública.

Como vimos, a denúncia caluniosa exige o dolo direto. Vale trazer aqui a opinião doutrinária do Procurador de Justiça Victor Rios Gonçalves (Direito Penal Esquemático - Parte Especial, item 14.4.2.2) (grifos conforme original):

A denúncia deve ser objetiva e subjetivamente falsa. Objetivamente, no sentido de que a pessoa contra quem foi imputada a infração não pode ter sido realmente a sua autora. Ex.: João imputa crime a Antonio, supondo-o inocente. Posteriormente, por coincidência, fica apurado que este realmente havia praticado o crime. Nesse caso não há denúncia caluniosa, pois a imputação não era objetivamente falsa. Subjetivamente falsa significa que o denunciante deve ter plena consciência de que está acusando uma pessoa inocente. O crime de denúncia caluniosa só admite o dolo direto, sendo, assim, incompatível com o dolo eventual. Desse modo, se o denunciante tem dúvida acerca da responsabilidade do denunciado e faz a imputação, não há crime, mesmo que se apure posteriormente que o denunciado não havia cometido o delito. Só há crime, portanto, quando o agente sabe efetivamente da inocência da pessoa. Ademais, se alguém se limita a dizer que supõe que Antonio cometeu certo crime, não pratica denúncia caluniosa, mesmo que Antonio seja inocente. Porém, se a pessoa sabe que Antonio não cometeu o crime e diz que acha que foi ele o autor do crime (apenas para disfarçar), existe a denúncia.

As circunstâncias apontadas pela acusação não permitem concluir pela existência do elemento subjetivo exigido pelo tipo.

Em primeiro lugar aponto que a audiência de custódia ou audiência de apresentação é feita em benefício da pessoa presa de modo que devem ser vistas com extremas reservas o uso contrário a ela do que se fala nessa ocasião.

Aliás, novamente trago a lição do referido Procurador de Justiça:

Requisito da denúncia é a espontaneidade, ou seja, a iniciativa deve ser exclusiva do denunciante. Assim, se ele faz a acusação em razão de questionamento de outrem, não existe o crime. Ex.: réu que atribui o crime a outra pessoa em seu interrogatório.

Ou seja, o relato das pessoas presas em audiência de apresentação acerca de violência policial carece da referida espontaneidade, visto que, conforme inciso VI do art. 8º da Resolução CNJ 213/2015, a pessoa presa deve ser questionada justamente a respeito disso.

Além disso, as declarações na fase policial acerca da ausência de eventuais agressões devem ser recebidas sempre com alguma reserva tendo em vista o constrangimento ambiental, seja porque ali é um cenário exclusivamente policial, seja porque muitas vezes ali não tem o amparo de quaisquer terceiros (inclusive da defesa técnica, que é um direito da qualquer pessoa acusada) que possam denunciar ou presenciar abusos. Aliás, é exatamente por isso que são as feitas as audiências de custódia ou de apresentação perante a autoridade judicial.

E, no caso concreto, foi justamente isso o alegado pelos réus em juízo.

Tampouco pode ser usado contra as pessoas presas o declarado por elas perante o médico. Primeiro porque o procedimento foi realizado em desconformidade com a alínea "d" do inciso VII do art. 8º da Resolução CNJ 213/2015. O relato das pessoas presas acerca da presença policial e da limitação desse exame à anamnese coincide com o relato de todos os outros presos na comarca; as "insuficiências" materiais a este respeito já são de ciência dos órgãos administrativos do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública.

Usar contra a pessoa presa o relato que ela faz na presença de seu suposto agressor é incompatível com as garantias judiciais deferidas às pessoas acusadas nos tratados internacionais assinados pelo Brasil.

A foto do carro de fls. 59 não permite inferir, nem de longe, que os ferimentos verificados nas pessoas imputadas foram causados pela colisão do veículo e não por eventual resistência delas ou por supostas agressões dos agentes públicos. Não há qualquer prova técnica minimamente conclusiva a este respeito.

Ademais, as declarações de resistência também tornam o cenário mais obscuro, e não mais claro como quer fazer parecer a acusação.

O que é certo é que as pessoas presas estavam lesionadas (ou feridas) no momento da prisão, conforme documentos de fls. 62/63 e 69/70, mas não se sabe precisar a causa de tais lesões (ou ferimentos).

Cenário este que não permite concluir nem pela culpa ou inocência dos policiais militares por eventual abuso de autoridade, nem pela culpa ou inocência das pessoas imputadas acerca da denúncia caluniosa.

De notar que já na ocasião da audiência de custódia, em sua manifestação final, o representante do Ministério Público concluiu pela veracidade do "auto de resistência" sem sequer colher a versão dos policiais a respeito das circunstâncias desta resistência; ora, somente conhecendo as alegações específicas dos policiais e das pessoas presas a respeito do modo como foi realizada a prisão, bem como do confronto de tais versões com as provas materiais é que se poderia ter uma conclusão fundada a respeito tanto do eventual abuso de autoridade, quanto da suposta denúncia caluniosa.

O que não se pode admitir é que no cenário atual, de pouco escrutínio sobre a atividade policial, isso chegue ao cúmulo de justamente ser usado contra as pessoas acusadas. Não será um processo penal justo.

Consigno que a mudança de versão de SAIN a respeito de ter presenciado as agressões contra JORGE não diz respeito à imputação que ele faz contra o policial que abordou, mas à imputação feita por JORGE contra o policial que abordou este; não se trata, portanto, da assunção da falsidade de seu relato, mas da falsidade de seu testemunho a respeito da imputação feita por JORGE. Poderia responder, em tese, pelo delito de falso testemunho, não por denúncia caluniosa.

Por fim, vê-se que as duas pessoas imputadas confessaram os outros dois delitos, exceto a denúncia caluniosa. Eram pessoas de fora da cidade, não conheciam e não eram conhecidos dos policiais; as alegações seriam incapazes de alterar a situação deles na audiência de custódia, visto que as alegações era de fatos posteriores ao flagrante. Não há sequer motivos para a falsa incriminação.

Quanto às demais imputações, é o caso de reconhecer a existência delas, seja pela confissão, seja pelo relato de Laura e dos policiais, bem como das demais provas

materiais juntadas e já citadas.

Todavia, com razão a defesa quando pede a consunção. Isso porque não se tem notícia do uso do veículo em contexto autônomo ao destes autos, sendo absolutamente crível a versão de que fizeram a alteração das placas do veículo com o intuito de não serem descobertos pelo furto.

Nesse contexto, o delito do art. 311 do Código Penal tornou-se, diante do plano concreto de execução dos autores, um meio de passagem para o delito de furto, não sendo aplicado o concurso de crimes.

Qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal): para sua caracterização é necessário que a violência seja praticada contra o obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando os vestígios tiverem desaparecido.

No caso em exame, houve deterioração."destruição do sistema de trava e cadeados do portão social, seguido de arrombamento da porta da sala caracterizado por destruição total e extração do miolo da fechadura da porta de folha metálica", conforme laudo de fl. 285/289.

Qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal): para sua caracterização é preciso a participação de duas ou mais pessoas na conduta criminosa, incluindo-se no cálculo o co-autor inimputável, o agente não identificado, aquele que age sob escusa absolutória (art. 181 do Código Penal) e até mesmo o coautor ou partícipe que não estava na cena do crime.

No caso em exame, ficou comprovada a participação de duas pessoas.

A recuperação dos bens, por si só, não permite a incidência da insignificância.

A devolução do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

STJ, AgRg no AREsp 1203702/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para

perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.
É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas

a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.
AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, "reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa" (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não

haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. O Ministério Público apontou quatro maus antecedentes para Jorge (autos 0013128-51.2004.8.26.0001; 0003219-43.2011.8.26.0472; 0000946-85.2007.8.26.0079; 0004262-35.2010.8.26.0101; 0008351-21.2020.8.26.0451) sendo que cada um, por si só, enseja um aumento de 1/6 (sexto) no intervalo de pena.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF – HC 593.818/SC).

O delito foi cometido invadindo uma residência, o que configura uma circunstância especialmente grave. A Constituição protege a casa afirmando a sua inviolabilidade no inciso XI do art. 5º. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a

tutela de bens jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua violação. Assim, a violação da residência para a consecução do furto extrapola demasiadamente aquilo que está insito ao tipo penal constituindo circunstância especialmente grave ensejando exasperação da pena próximo ao limite máximo. Entretanto, para evitar desproporcionalidade, em razão da sanção estabelecida pelo art. 150 do Código Penal, limito o aumento a três meses e 24 dias-multa. Devida a elevação da pena em razão do elevado valor dos bens alvejados pelas pessoas imputadas, razão pela qual aumento a pena em mais dois anos e 116 dias-multa.

Comprovada a circunstância do rompimento de obstáculo, pela qual a lei confere especial gravidade ao delito dobrando a sua faixa de pena, e bastando a circunstância do concurso de pessoas para qualificar o furto, aumento a pena em mais dois anos e 116 dias-multa.

Embora absorvida a infração do art. 311 do Código Penal, o fato é uma circunstância especialmente negativa merecendo um aumento de um ano e 58 dias-multa.

A pena-base de Jorge fica no máximo legal. A de Sain fica em sete anos e três meses de reclusão e 324 dias-multa.

Segunda etapa. Ambos confessaram o delito.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (Sain 0011182-28.2017.8.26.0635 e 0009790-71-2014.403.6119; Jorge 0045875-13.2018.8.26.0050 e 000768-54.2016.8.26.0554). Prevalece a última implicando um aumento de 1/6 (um sexto), resultando a pena de ambos no máximo legal.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

A reincidência específica (Sain 0011182-28.2017.8.26.0635; Jorge 0045875-13.2018.8.26.0050 e 000768-54.2016.8.26.0554) e a negativa das circunstâncias judiciais exigem o regime fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR SAIN MORENO AGUILAR à pena de reclusão, pelo prazo de oito anos, em regime inicial fechado, bem como a 360 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal; e CONDENAR JORGE PATRÍCIO RODOURA HIDALGO à pena de reclusão, pelo prazo de oito anos, em regime inicial fechado, bem como a 360 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

ABSOLVO os acusados da imputação de denúncia caluniosa nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal e da imputação de falsificação de sinal de identificação de veículo automotor nos termos do inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta dos acusados, as razões das prisões cautelares (fls. 133/139) estão mantidas, até porque o risco de reiteração só foi neutralizado neste período justamente por conta da restrição da liberdade.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a

imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para os defensores que atuaram na audiência de apresentação.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Sendo os condenados estrangeiros e havendo risco de imposição de regime carcerário, deverá a serventia dar ciência da sentença aos consulados respectivos.

Cópia desse documento assinada digitalmente servirá como ofício.

Friso, por fim, que, nos termos da Portaria CPMIG/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJSP Nº 3057, de 18 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União do dia 19 de março de 2021, foi determinada a EXPULSÃO de SAIN MORENO AGUILAR do território nacional, a qual deverá ser executada após o cumprimento da pena ou liberação pelo judiciário (fls. 252/253).

Nos termos da Resolução CNJ 162/2012 determino o encaminhamento dos passaportes das pessoas presas aos respectivos consulados.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 25 de abril de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA